

1502211-61.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261619/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 27639485 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marco Antonio Cunha dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502211-61.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502211-61.2022.8.26.0616 - 1135/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261619/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 27639485 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marco Antonio Cunha dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

MARCO ANTONIO CUNHA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 18h00min, na

Rua Guararapes, nº 26, Vila Acarati, nesta comarca de Poá, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 102 porções de cocaína na forma de crack, pesando 12,7g, 3 porções de cocaína na forma de crack, pesando 4,0g, 65 porções de cocaína, pesando 40,1g e 80 porções de maconha, pesando 152,4g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 89, 97/99).

A denúncia foi recebida em 3 de novembro de 2022 (fls. 109/110).

O réu foi citado (fls. 120).

Durante a instrução, foram ouvidos o acusado e duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/2, 5/10), boletim de ocorrência (fls. 34/36), auto de exibição e apreensão (fls. 3/4), laudo de constatação (fls. 18/22), comprovante de depósito (fls. 68) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 90/92).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu "negou os fatos a ele imputados, afirmando que os guardas municipais acharam uma bolsa contendo drogas, afirmaram que seria do interrogado e por isso conduziram-no a esta unidade. Quanto à sua integridade física, afirmou que não está lesionado e não foi agredido em momento algum desta ocorrência. Não possui filhos." (fls. 5).

Em juízo, sustentou que, na data dos fatos, passou na biqueira para comprar uma porção de 'crack', momento em que foi abordado pelos guardas municipais. Disse que estava em poder de R\$ 20,00, cujo valor pediu emprestado a seu patrão. Asseverou que foi preso, porque tem passagem criminal. Alegou que trabalhava como ajudante de pedreiro. Negou conhecer as testemunhas e não apresentou ressalvas em relação a elas. Explicou que a sacola apreendida pertencia ao traficante, que fugiu.

A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos.

Eduardo Brendo Nogueira e Silva, guarda civil municipal, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina no endereço descrito na denúncia, que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, ocasião em que visualizou o réu.

Narrou que o acusado, ao perceber a presença da viatura, apresentou nervosismo e tentou fugir a pé, momento em que dispensou uma sacola, mas foi detido. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, dentro da sacola dispensada, foram localizadas porções de cocaína, 'crack' e maconha, mas não se lembrou se houve apreensão de dinheiro. Questionado, o réu permaneceu em silêncio. Reconheceu o acusado. Negou conhecê-lo.

Semelhante é o depoimento de Gabriel de Souza Lima.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssomos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar

peessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

Vale lembrar que, no caso em testilha, o acusado estava em situação de flagrância quando foi abordado pelos guardas municipais, pois estava na posse de drogas, que estavam na sacola carregada por ele.

Logo, a atuação dos guardas municipais não era voltada à investigação, mas destinada a efetuar a prisão em flagrante, cuja conduta encontra respaldo no artigo 301 do Código de Processo Penal, razão pela qual a r. decisão proferida no RE nº 128177/SP não se enquadra na hipótese dos autos.

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas municipais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341), o que afasta a tese de desclassificação.

Aliás, para que ocorra a desclassificação, é necessário que a Defesa comprove efetivamente que o acusado é usuário de droga. Não basta a simples afirmação. Caso contrário, todo acusado que alega ser usuário de entorpecente (o que acontece com a maioria e com o objetivo de se livrarem da responsabilidade criminal) teria sua conduta desclassificada, o que acarretaria expressiva impunidade.

Vale lembrar que eventual consumo de entorpecente não afasta a traficância, já que o usuário é um potencial traficante, que faz da mercancia ilícita a forma de sustento de seu vício.

Nessa toada:

"TÓXICOS - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Descabimento - Agente surpreendido quando guardava cerca de 200 gramas de cocaína - Expressiva quantidade da droga apreendida que, aliada à maneira como estava acondicionada, aos depoimentos dos policiais e ao fato de o réu se dizer desempregado, evidencia a prática do tráfico de entorpecente, sendo que o fato de o acusado ser usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, mesmo porque o comércio ilícito é freqüentemente utilizado para obtenção do dinheiro necessário à manutenção do vício e ao próprio sustento - Recurso improvido" (Apelação Criminal n. 993.08.026446-5 - Araras - 9ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Coelho - 23.07.08 - V.U. - Voto n. 6513).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

"Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes" (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Nesse ponto, importante ressaltar que o réu não demonstrou possuir ocupação lícita a justificar a posse do dinheiro (alegou que trabalhava como ajudante de pedreiro, mas não ficou demonstrado que exercia tal atividade à época dos fatos).

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos guardas municipais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude - Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98" (RT 772/568). "Pena - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto." (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu, que é reincidente específico (fls. 37 - proc. 1501924-35.2021), foi preso em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas (250 porções de drogas, entre cocaína, 'crack' e maconha), conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias, o que revela a gravidade concreta do delito. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita (declarou que trabalhava como ajudante de pedreiro, mas não demonstrou tal atividade). Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, crack e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Além do mais, o réu possui passagem pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas (fls. 39), o que revela desvio de personalidade. Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, verifico o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito. De outro lado, presente a atenuante da menoridade, compenso-a com a agravante descrita no parágrafo anterior.

Além do mais, presente a agravante da reincidência específica (fls. 37 - proc. 1501924-35.2021). Portanto, considerando que a reincidência específica é mais gravosa que a comum, tanto que impede a concessão de benefícios, como o livramento condicional para os delitos hediondos e seus assemelhados ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, elevo a pena em 1/3, totalizando 8 anos e 4 meses de reclusão e 830 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu é reincidente específico, o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas. Registra-se, ainda, que o acusado não comprovou que possuía ocupação lícita, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilegal.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Além do

mais, é reincidente específico e a pena anteriormente fixada não foi suficiente para ressocializá-lo. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 49/50). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar MARCO ANTONIO CUNHA DOS SANTOS à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 830 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA